

0000619-37.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000619-37.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000619-37.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOEL BARBOZA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JOEL BARBOZA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), no artigo 121, § 2º, I, c.c. o art. 14, inciso II, e no art. 147, por duas vezes, do Código Penal, todos em concurso material, afirmando que em 24 de maio de 2020, no período da manhã, na rua José Marques Castelhana, nº 351, Vila Sibila, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, (1) praticou vias de fato contra sua esposa Maria Cristina Bressam Barbosa desferindo um golpe em sua cabeça; (2) além de ter ameaçado por palavras ela, bem como, seu filho Diego Rafael Bressam Barboza, dizendo, assim que sua esposa saiu de casa, que "quando ela voltasse iria bater nela" e que iria matar o filho; (3) por fim, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, tentou matar seu filho golpeando-o com uma faca na região da testa, tendo o crime não se consumado devido à intervenção da vizinha Fabiana, que recolheu Diego em sua residência e acionou a Polícia Militar.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "JOEL e Maria Cristina são casados há trinta e cinco anos, havendo entre eles histórico de violência doméstica e familiar e possuem dois filhos do relacionamento, sendo um deles deficiente mental. Na data dos fatos, pela manhã, JOEL começou a beber cerveja e passou a apresentar certa alteração no comportamento, razão pela qual a vítima Maria Cristina lhe disse que iria sair de casa e voltar mais tarde, no que o denunciado, contrariado com tal situação, ameaçou a esposa dizendo "quando você

voltar vou te bater" e, ato contínuo, aproximou-se e praticou vias de fato contra ela desferindo um golpe em sua cabeça, sem, contudo, causar-lhe lesões. Na sequência, Maria Cristina saiu da residência e se dirigiu à casa de sua cunhada, momento em que foi avistada aos prantos pela vizinha Fabiana Julia da Silva Utinete. Na sequência, JOEL iniciou uma discussão com seu filho Diego, que é deficiente mental, e, visando matá-lo, acabou por golpeá-lo com uma faca na região da testa, tendo este gritado por socorro e sido, então, auxiliado pela vizinha Fabiana, que o recolheu em sua residência e acionou a Polícia Militar. O denunciado, ainda, ameaçou Diego, dizendo que iria matá-lo. Na sequência, com a chegada dos policiais, JOEL foi preso em flagrante e a faca utilizada no crime localizada e apreendida (fl. 22). As vítimas Maria Cristina e Diego ofertaram representação (fls. 05 e 06). O homicídio só não se consumou devido a intervenção de Fabiana, que evitou o mal maior. O homicídio tentado foi praticado por motivo torpe, eis que a conduta do denunciado decorreu de seu próprio destempero em razão do uso de bebida alcoólica." A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais. O acusado foi pronunciado em 16/09/2020 conforme cópia de sentença acostada às fls. 323/333. A defesa interpôs recurso em sentido estrito com cópia às fls. 338/344. O Ministério Público ofereceu contrarrazões com cópia às fls. 349/352. O acórdão de fls. 380/384 deu provimento em parte ao recurso e desclassificou o delito de tentativa de homicídio para o delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal). Por decisão de fls. 420, o feito foi desmembrado e as imputações de ameaça e vias de fato foram encaminhado ao Juizado Especial desta comarca para nova distribuição; com relação ao crime de lesão corporal, o magistrado declarou que já havia se manifestado sobre o feito, afirmando que o réu não teria um julgamento imparcial, desta forma determinou a remessa dos autos a sua substituta legal. Por decisão de fls. 441/443, a MM. Juíza deferiu o requerimento do Ministério Público de fls. 439, determinando o retorno dos autos que haviam sido remetidos ao Juizado Especial para a justiça comum. Por decisão de fls. 454, foi aceita a redistribuição do feito e dando prosseguimento juntou-se certidão de objeto e pé às fls. 467/473 com a sentença onde se apurou o crime de lesão corporal. O Ministério Público requereu o aproveitamento dos atos processuais praticados nos autos de origem (fls. 477), com o expressa concordância da defesa (fls. 484), desta forma, o processo seguiu seu trâmite com oferecimento de alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 147 do Código Penal assim descreve o delito de ameaça:

Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave .

O tipo objetivo consiste na conduta de intimidar alguém com a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando se o agente tenha o propósito de executar o que promete. O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui elemento subjetivo. Basta a intenção de intimidar, traduzido em palavras ou atos capazes de provocar temor na vítima. O estado de ira ou cólera não exclui o dolo; pelo contrário, a ira e a cólera reforçam a ameaça e causam ainda mais temor na vítima.

O objeto material é a pessoa da vítima, enquanto que o objeto jurídico é a paz de espírito, a segurança e a liberdade da pessoa humana.

É crime formal e se consuma no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça; o delito se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave.

O crime é de ação penal pública condicionada (parágrafo único do art. 147 do Código Penal). A lei não exige forma específica para a representação, de modo que basta a notícia do crime à autoridade policial, p. ex., para se suprir o requisito legal.

O tipo previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais pune aquele que exerce desforço físico contra alguém sem lhe causar lesões, pois tal resultado implica tipificação do art. 129 do Código Penal.

No caso em exame, há prova da existência do crime de ameaça e de sua autoria. A existência do crime de ameaça está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima, Maria Cristina Bressam Barboza, na fase policial disse que "é casada com JOEL BARBOZA ha trinta e cinco anos e fruto do relacionamento tem dois filhos, sendo certo que um é deficiente mental; que na data de hoje pela manha, JOEL, começou a beber cerveja e no instante que percebeu certa alteração no comportamento de JOEL, disse ao mesmo que iria sair de casa e voltar mais tarde; que Joel acabou ficando bravo com o comportamento da declarante e ameaçou "quando você voltar vou te bater"; que neste instante Joel se aproximou e desferiu soco em sua cabeça, sem contudo gerasse alguma lesão; que após isso saiu de casa normalmente e foi para a casa de sua cunhada e lá teve o conhecimento que houve uma briga entre seu filho e Joel em que este veio a ferir seu filho com uma faca não sabendo detalhes do evento; Que são constantes as ameaças de morte de Joel contra seu filho; que a declarante já foi agredida inúmeras vezes e Joel já foi preso por crime de violência doméstica; que a declarante teme por sua vida e neste ato deseja representar contra Joel pelas ameaças e lesões contra si e seu filho DIEGO RAFAEL BRESSAM BARBOZA, o qual é analfabeto e não sabe ler e escrever." Em juízo disse que entre 12h e 12h30min JOEL ligou o som e Diego estava na internet; saiu de casa para não discutir com Joel por conta do som alto; às 12h45min ficou sabendo dos fatos; encontrou sua colega Sueli no meio do caminho e lhe pediu dinheiro para o mototáxi; quando estava almoçando na casa de sua cunhada foi avisada que houve uma tragédia em sua casa. JOEL havia tomado duas latinhas de cerveja. Não discutiu com JOEL. Não recebeu qualquer ameaça. Mentiu para o delegado, pois não teve ameaça, nem agressão contra ela. Fez isso pelo filho. Sempre gostou dele. Confirmou a ameaça, mas negou a agressão. Não tem medo dele. Seu filho tem déficit de atenção. Seu filho não quer tomar remédio. JOEL está desempregado há dois anos; família vive do LOAS que seu filho recebe. Não se sente ameaçada por JOEL. Seu filho não precisa de cuidados.

A suposta vítima, Diego Rafael Bressam Barboza, na fase policial disse que "é filho de JOEL BARBOZA e neste ato manifesta interesse em Representar Criminalmente contra o mesmo pela agressão contra si proferida com uma arma branca (faca); que, o declarante tem problemas médicos, está internado, sem condições de maiores esclarecimentos." Em juízo disse que as ameaças aconteceram; ele o ameaçou de bater no meio de uma briga de pai e filho; sua mãe não estava no ato e não foi ameaçada; quando ele foi lhe bater teve que se defender; seu pai quebrou um dedo; não sofreu nenhuma lesão. Foi uma briga de pai e filho; foi uma lesão simples; deu um ponto só no nariz; se pai quem pegou a faca; Diego apenas se defendeu. A vizinha lhe socorreu. Depois chegou o guarda e foi levado ao hospital, onde recebeu um laudo médico. Foi ver sua mãe somente no hospital. Na parte da manhã já havia discutido com seu pai; não teve discussão entre ele e sua mãe. Não se sente ameaçado pelo seu pai. Seu pai não teve a intenção de lhe matar; seu pai avançou por cima dele e ele se defendeu. Seu pai avançou com a faca; a faca lhe acertou no nariz, mas só deu um ponto. Era uma faca de cozinha de corte de carne.

A testemunha de acusação, Fabiana Julia da Silva Utinete, na fase pré processual disse que "é vizinha de MARIA CRISTINA BRESSA BARBOZA; Que hoje pela manha, viu MARIA CRISTINA BRESSAN BARBOZA, sair de casa chorando, não sabendo declinar o motivo; que passado um tempo ouviu JOEL discutindo em voz alta com DIEGO e no momento que este gritou por socorro, a depoente saiu para ver o que estava acontecendo; que neste instante viu JOEL, segurando DIEGO, estando com uma faca, segurando a faca; que diante disso, a depoente pegou DIEGO, levou para sua casa tendo acionado resgate e a Polícia; que no instante que Joel saiu do local este dizia que iria matar o filho, sendo certo que este tentou esconder a faca, mas sem

êxito pois os Policiais vieram a achar a faca; que as brigas no local são constantes e a depoente sempre ouve Joel gritar que vai matar Diego ou mesmo pratica agressões contra MARIA CRISTINA BRESSAN BARBOZA." Em juízo manteve sua versão. Viu Diego sofrendo os golpes na cabeça (na testa, perto da sobrancelha). Polícia foi chamada. Viu sempre muita agressão verbal de JOEL contra a mulher e Diego. Quando tirou Diego, Joel o ameaçou de morte ("quando voltar vou te matar") Diego tem um déficit. Diego é um menino super tranquilo, o conhece desde criança. A testemunha de acusação, o policial militar Irineu Luis Parolo, na fase pré processual, disse que "estava de serviço juntamente com o Pm Gomes na Vtr I-38405, quando foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de agressão, violência doméstica; que, ao chegar no local dos fatos foram informados que o autor JOEL BARBOSA havia agredido seu filho DIEGO RAFAEL BRESSAN BARBOZA, inclusive com uma facada na face; que, o indivíduo estava no local, ensanguentada e foi acionado o resgate para levá-lo ao PSM de Porto Ferreira; que, o autor do fato, JOEL BARBOSA estava meio alterado e foi encontrada a faca utilizada pelo mesmo para perpetrar a agressão; que, segundo informou uma testemunha, havia ocorrido uma agressão anterior de JOEL BARBOSA em face de sua esposa MARIA CRISTINA BRESSAN BARBOZA a qual fugiu do local; que, as partes foram levadas ao PSM tendo DIEGO RAFAEL BRESSAN BARBOZA permanecido internado; que, neste interím compareceu na Delegacia MARIA CRISTINA BARBOZA, a qual narrou a agressão e que tinha interesse em Representar, tendo sido levada também ao PSM." Em juízo manteve sua versão. Viu Diego sentado com um ferimento na testa; informação de Fabiano e de Diego era decorrente de uma facada dada por seu pai. Na delegacia a esposa dele apareceu e também disse ter sido agredida. JOEL estava nervoso e agitado. Filho lhe disse que houve uma briga entre os dois e lhe desferiu um golpe na testa. Já atendeu outras ocorrências envolvendo aquela família.

A testemunha de acusação, o policial militar Willians Roberto Gomes Pinto, na fase pré processual disse que "estava de serviço juntamente com o Pm Parolo na Vtr I-38405, quando foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de agressão, violência doméstica; que, ao chegar no local dos fatos foram informados que o autor JOEL BARBOSA havia agredido seu filho DIEGO RAFAEL BRESSAN BARBOZA, inclusive com uma facada na face; que, o indivíduo estava no local ensanguentada e foi acionado o Resgate para levá-lo ao PSM de Porto Ferreira; que, o autor do fato, JOEL BARBOSA estava meio alterado e foi encontrada a faca utilizada pelo mesmo para perpetrar a agressão; que, segundo informe de uma testemunha, havia ocorrido uma agressão anterior de JOEL BARBOSA em face de sua esposa MARIA CRISTINA BRESSAN BARBOZA a qual fugiu do local; que, as partes foram levadas ao PSM tendo DIEGO RAFAEL BRESSAN BARBOZA permanecido internado; que, neste interím compareceu na Delegacia MARIA CRISTINA BARBOZA, a qual narrou a agressão e que tinha interesse em Representar, tendo sido levada também ao PSM." Em juízo manteve sua versão. Agressão foi na cabeça. Vizinha Fabiana teria visto tudo. Ferimentos foi na parte frontal da face; estava muito ensanguentado. Encontraram a faca de porte médio/grande. Apresentaram o instrumento na delegacia. Já existiram outras ocorrências envolvendo esta família. Ele e Irineu que conduziram todos à delegacia. JOEL estava exaltado e agitado (com tom ameaçados). Teve atritos com o filho. Diego era bem certo no que dizia; afirmava que o pai queria matá-lo; não presenciou ameaças na delegacia, pois as partes foram separadas; não se lembra de ato de carinho entre as partes JOEL BARBOZA, em declarações perante a autoridade policial, disse que "é casado com MARIA CRISTINA BRESSAN BARBOZA ha trinta e cinco anos, fruto do relacionamento tem dois filhos; que seu filho DIEGO RAFAEL BRESSAN BARBOZA, o qual conta hoje com 18 anos, possui problemas mentais, não sabendo declinar a patologia mas acredita que seja algo relacionado a deficit de atenção; Que na data de hoje estava em sua casa quando em dado momento seu filho, sem qualquer motivo, pegou uma faca e foi em sua direção com a intenção de feri-lo; que tentando se defender acabou dando um golpe de baixo para cima, contra a mão que seu filho segurava a faca e em razão disso acabou resvalando na testa do mesmo, causando uma lesão que conseguiu tirar a faca do seu filho e correu para fora de casa; que pediu socorro a vizinhos, sendo acionada a Polícia e o resgate, sendo seu filho socorrido; que sua esposa não estava em casa no instante que ocorreu o entrevero entre o interrogando e seu

filho; que sua esposa saiu de casa mais ou menos meia hora antes do ocorrido e está vendo somente a mesma aqui nesta Delegacia; que, o interrogando afirmou que não houve qualquer entrevero com sua esposa; que não houve sequer discussão, tampouco agressão ou qualquer atitude compatível com violência doméstica; que já foi preso crime de violência doméstica; que não conhece os policiais que o prenderam; que não sofreu agressões dos policiais; que apresenta lesões no dedo, na perna e no braço, resultado do entrevero ocorrido com seu filho." Em juízo manteve sua versão. No dia tomou duas latas de cerveja; ligou o som, mas Diego derrubou o som no chão; Diego partiu para cima dele com a faca; ao se defender a faca bateu na testa dele. Não agrediu Maria Cristina, nem a ameaçou (disse que se ela não voltasse iria "escutar"). Não ameaçou seu filho. Gosta do seu filho e já passou a casa para o nome dele. Voltou para casa porque sua mulher ficou doente; não frequenta mais bares. Quem socorreu Diego foi Sueli.

Como se vê, notadamente pela versão da suposta vítima Maria Cristina, as imputações de ameaça e vias de fato não encontraram respaldo na prova produzida em contraditório.

Jé em relação à imputação que tinha por ofendido Diego, o relato dele, bem como o da testemunha Fabiana, fornecem um substrato seguro para a condenação.

Configurado, assim, o delito de ameaça (topo do artigo 147 do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "detenção, de um a seis meses, ou multa".

Passo a dosar a pena.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos -

diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, "reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa" (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser

aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Diante do art. 17 da Lei 11.340/06 é proibida a aplicação da pena alternativa de multa prevista no topo do art. 147: "ou multa".

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que a ameaça foi de morte. Embora a promessa de mal injusto e grave faça parte do tipo penal, a ameaça de morte não está insita à figura do art. 147, tratando-se, em verdade, da expressão do delito em um dos seus maiores graus, razão pela qual enseja um aumento de três meses.

Em razão dos maus antecedentes (autos 000037-52.2012.8.26.0472; 0001152-84.2007.8.26.0472; 0005429-80.2006.8.26.0472) fixo a pena no seu máximo legal.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF – HC 593.818/SC).

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

A negativa das circunstâncias judiciais exige o regime semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

V - A pacífica jurisprudência deste Tribunal estabelece que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie.

VI - A despeito do montante final da pena autorizar, a princípio, o regime aberto, depreende-se da dosimetria realizada que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, que possui maus antecedentes, o que justifica o agravamento do regime prisional, para o semiaberto, consoante orientação do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

HC 408266/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/08/2013.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JOEL BARBOZA à pena de detenção, pelo prazo de seis meses, em regime inicial semiaberto, em virtude da conduta típica descrita no topo do art. 147 do Código Penal; e para ABSOLVER o acusado das imputações de ameaça e vias de fato contra Maria Cristina por insuficiência de provas.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA